

Avv. Paolo Caruso
Via Eustachio Manfredi n. 5
00197 – Roma
Tel. 06.8084487 - Fax 06.87813040
paolocarus@ordineavvocatiroma.org
paolo.caruso@legalecaruso.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

ATTO DI CITAZIONE

IN OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

per **FASTWEB S.p.A.** (C.F. e P.IVA 12878470157), Società a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom A.G., con sede legale in Piazza Adriano Olivetti 1, 20139 – Milano (MI), in persona della Dott.ssa Simona Serchi, nella sua qualità di procuratore, per procura del 4.12.2023, Rep. n. 42295, Racc. n. 16755, notaio E. Terrenghi, rappresentata e difesa, per procura speciale rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Paolo Caruso (C.F. CRSPLA79R09H501Y; PEC paolocarus@ordineavvocatiroma.org; telefax 06.87813040), con domicilio eletto presso l'indirizzo p.e.c. del suddetto difensore e presso il suo Studio in Via Eustachio Manfredi 5, 00197 – Roma (RM);

CONTRO

il **COMUNE DI BERBENNO** (C.F. e P.IVA 00313890162), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Via Europa n. 7 – 24030 Berbenno (BG), PEC: comuneberbenno@legalmail.it (Registro IPA)

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA

dell'avviso di accertamento esecutivo n. 1 del 06.02.2025 (doc. 1) emesso dal Comune di Berbenno (BG), notificato via p.e.c. il 15.02.2025, per il preteso pagamento del *“canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* di cui all'art. 1, comma 816 della Legge n. 160/2019, per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024, in pretesa applicazione dell'art. 1, comma 831 della Legge n. 160/2019 (cavi e condutture), per il ritenuto *“utilizzo in via mediata della rete di proprietà del soggetto titolare della concessione, attraverso collegamenti tecnologici, senza che sia quindi necessaria alcuna occupazione fisica o modificazione della realtà”*.

* * * * *

PREMESSA IN FATTO

1. L'avviso di accertamento esecutivo.

Con **avviso di accertamento esecutivo** n. 1 del 6.2.2025 (**doc. 1**), notificato via p.e.c. il 15.2.2025 (**doc. 2**), il Comune di Berbenno, richiamata la normativa sul canone unico patrimoniale e il relativo Regolamento comunale (**doc. 3**), ha intimato a Fastweb S.p.A. di pagare entro sessanta giorni la somma complessiva di **€ 7.173,00**, con la seguente specifica:

- quanto a € 800,00 a titolo di “*canone unico patrimoniale*” per l’anno 2021;
- quanto a € 830,40 a titolo di “*canone unico patrimoniale*” per l’anno 2022;
- quanto a € 924,24 a titolo di “*canone unico patrimoniale*” per l’anno 2023;
- quanto a € 929,79 a titolo di “*canone unico patrimoniale*” per l’anno 2024;
- quanto a € 3.484,43 a titolo di “*sanzione amministrativa pecuniaria*”, fissata in misura pari al canone non versato per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024;
- quanto a € 204,43 per “*interessi*”, decorrenti dalla scadenza di ciascuna annualità del canone unico patrimoniale.

Nella sezione “*motivazione dell’atto*” viene precisato che il canone sarebbe dovuto “*per l’utilizzo in via mediata della rete di proprietà del soggetto titolare della concessione*” e, dunque, a prescindere dall’esistenza di un’occupazione e indipendentemente dall’utilizzo materiale dell’infrastruttura.

Inoltre, ai sensi dei commi 792 e ss. dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che disciplinano l’avviso di accertamento esecutivo, l’atto avverte della propria idoneità ad acquistare “... *efficacia di titolo esecutivo*”.

* * * * *

L’avviso di accertamento esecutivo viene impugnato, in quanto nullo, illegittimo ed erroneo per i seguenti

MOTIVI

(I)

FALSA APPLICAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 831, DELLA LEGGE 160/2019 COME AUTENTICAMENTE INTERPRETATO. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. INSUSSISTENZA DI RAPPORTI CONCESSORI CON IL COMUNE. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI FASTWEB

L'avviso di accertamento viene impugnato per insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, come interpretato dall'art. 5, comma 14-*quinquies* del D.L. n. 146/2021, convertito con Legge n. 215/2021, e per difetto di legittimazione passiva di Fastweb.

Infatti, il servizio pubblico di telefonia fissa è erogato da Fastweb nel Comune di Berbenno senza una propria rete e senza propri apparati collocati sul territorio. Pertanto, non si realizza il presupposto della occupazione di suolo pubblico, che consentirebbe di applicare anche nei suoi confronti il canone patrimoniale unico. Fastweb, dunque, da un lato, come pacifico, non è titolare di alcuna concessione di suolo pubblico; dall'altro lato, come pure è pacifico, non è occupante abusiva e pertanto non ha ragione di richiedere il rilascio di una concessione di suolo pubblico a proprio nome.

*

I.1 Riferimenti normativi: l'art. 1, co. 831, e l'interpretazione autentica.

L'art. 1 della **Legge n. 160/2019** (Legge di Bilancio 2020), ai commi 816 e ss., ha previsto l'istituzione da parte dei Comuni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, **c.d. canone unico patrimoniale**, che, a decorrere dal 2021, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e altri prelievi similari, e ha

stabilito (comma 819) che “il **presupposto del canone** è: a) l'**occupazione**, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva...”.

Il successivo **comma 831**, nel testo ora vigente, ha poi stabilito:

“Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni abitanti oltre 20.000	euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente **non può essere inferiore a euro 800**. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete”.

Il **comma 831** ha formato oggetto di **interpretazione autentica**, ad opera del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, il cui art. 5, comma 14-*quinquies*, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, dispone:

“Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una **separazione**, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, **tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale**, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, **il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto**

titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.

Insomma, a fronte di un apparente contrasto tra il concetto di occupazione “*in via mediata*” e il pur necessario presupposto dell’ “*utilizzo materiale*” delle infrastrutture, si è espressamente precisato che, quando il soggetto che fornisce il servizio all’utenza si avvale di infrastrutture altrui, cioè opera in forza di contratti intercorsi con il titolare dell’infrastruttura, è quest’ultimo che, quale concessionario, rappresenta l’unico soggetto passivo del canone patrimoniale. È questo il caso di specie, come ora si vedrà.

I.2 Il servizio espletato da Fastweb e modalità tecnico-contrattuali di erogazione del servizio nel territorio comunale.

Fastweb S.p.A. è un operatore di telecomunicazioni titolare di licenze e autorizzazioni per la prestazione del servizio pubblico di comunicazione fissa e, in via integrata, per l’erogazione di servizi mobili tramite accordi di *partnership* e modalità di *virtual network operator*. Le attività di Fastweb rientrano nel quadro normativo previsto dal D.Lgs. n. 259/2003 c.d. “Codice delle comunicazioni elettroniche” (come modificato dal D.Lgs. n. 207/2021, attuativo della Direttiva (UE) 2018/1972 dell’11.12.2018, che istituisce il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche), secondo il quale “*la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (...) è di **preminente interesse generale***” (art. 3).

Per quanto riguarda la c.d. rete fissa, Fastweb assicura il servizio sia attraverso impianti propri che mediante convenzioni di servizio.

Il servizio di rete fissa di Fastweb passa per una **distinzione fondamentale**:

- in taluni casi Fastweb è titolare dell’intero collegamento tra la propria Rete Primaria, le proprie centrali e la “presa” del cliente, e si avvale di una **propria Rete di Accesso**, cioè proprie centraline di diramazione e propri

collegamenti in cavi di fibra ottica, entrambi posti lungo le strade del territorio comunale; in questi casi, Fastweb si fa carico del collegamento completo tra la propria centrale (Core Network) e l'abitazione del cliente;

- in molti altri casi, invece, il collegamento tra la “Rete Primaria” di Fastweb e la presa del cliente avviene attraverso l'utilizzo, parziale o completo, di **servizi per il collegamento e/o impianti e/o cavi e/o centraline forniti da altri soggetti** che, tramite le proprie infrastrutture, forniscono servizi di collegamento Wholesale (all'ingrosso) in favore di altri operatori (c.d. OAO: Others Authorised Operator, oppure OLO: Other Licensed Operator). Tra i soggetti titolari delle infrastrutture, oltre all'ex monopolista TIM – Telecom Italia S.p.a. (da luglio 2024 Fibercoop), quale titolare della maggior parte delle infrastrutture di rete fissa della c.d. “Rete di Accesso”, cioè dei cavi posti lungo le strade che, diramandosi, entrano materialmente negli immobili degli utenti, vi è anche **Open Fiber S.p.A.**, operatore che si occupa della realizzazione, gestione e manutenzione della rete in fibra ottica. Il fornitore di questi servizi rappresenta - ai sensi del comma 831 dell'art. 1 della L.160/2019 – il **titolare della concessione per l'occupazione del “territorio comunale”**, comprensivo – secondo la definizione del precedente comma 819 – delle **“aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”**.

Insomma, **i predetti operatori infrastrutturali (TIM, Open Fiber) forniscono** agli altri Operatori (detti OAO, *Other Authorised Operators* o anche OLO, *Other Licensed Operators*), **attraverso le proprie infrastrutture e cavi, il servizio di collegamento all'utente finale**. Questo servizio di collegamento, a sua volta, può essere realizzato mediante tecniche diverse (VULA, NGA, ed altri servizi di accesso...).

Ad esempio, la modalità tecnica di collegamento e il relativo contratto può essere BITSTREAM NGA (*Next Generation Access*), tipologia di accesso che prevede che l'Operatore sia presente (non sul territorio, né nella centrale del concessionario) esclusivamente in un punto di raccolta collocato a monte; oppure può essere VULA (*Virtual Unbundled Local Access*), tipologia di accesso che prevede che l'Operatore sia presente (non sul territorio ma) esclusivamente nella centrale del concessionario con un apposito kit di consegna; oppure servizi punto-punto, ad esempio, GEA, BEA, dark fiber.

Con tali modalità di accesso, utilizzate anche nel territorio del Comune convenuto, Fastweb può offrire servizi di connessione (sia FTTC che FTTH) ai propri clienti senza essere presente con la propria rete né lungo le strade con propri cavi e cabinet e nemmeno nei cavi di diramazione che entrano negli immobili degli utenti (e, nel modello NGA, nemmeno nelle centrali del concessionario).

Quindi, per quanto qui interessa, la connessione del cliente viene gestita da Open Fiber.

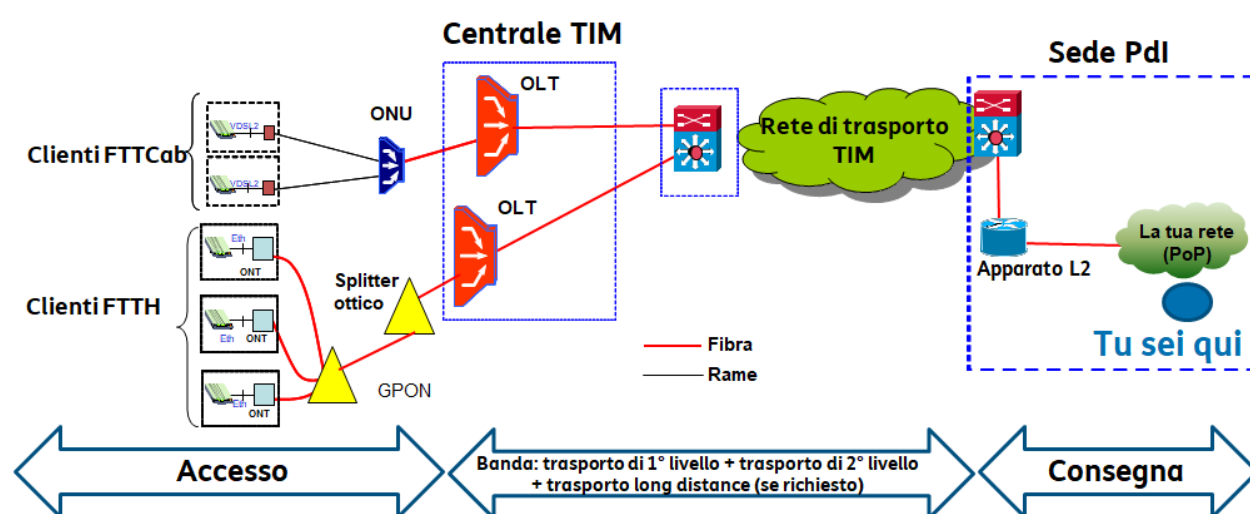
Del servizio fornito da Open Fiber all'ingrosso si fa cenno anche sul sito istituzionale, dove si rappresenta che *“La nostra infrastruttura in fibra ottica è disponibile per tutti gli Operatori di telecomunicazioni a pari condizioni. Pertanto, qualunque soggetto, purché detenga le necessarie autorizzazioni e previa sottoscrizione di un apposito contratto, potrà richiederci un segmento di terminazione. In questa sezione potrai trovare gli Operatori che hanno deciso di utilizzare la nostra rete FTTH”* (**doc. 4**, con elenco dei numerosi Operatori che hanno concluso accordi con Open Fiber, tra i quali, a pag. 6, figura Fastweb).

Si consideri che i contratti di cui sopra realizzano assetti non riconducibili al libero mercato, sia perché l'operatore infrastrutturale **è tenuto a consentire agli Operatori c.d. OLO l'accesso al servizio**, sia perché le relative **condizioni contrattuali**, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di quelli dettati

dall'Autorità di Regolazione, sono **uniformi per tutte le Società di vendita**. (si veda, in particolare, la Delibera n. 538/13/CONS dell'Agcom: **doc. 5**)

Le descritte modalità tecnico-contrattuali sono peraltro notevolmente onerose per Fastweb, che è tenuta a compensare il fornitore dell'infrastruttura per il servizio di collegamento attraverso la Rete di Accesso oltre che per la manutenzione e gli oneri di occupazione di suolo pubblico. Fastweb, infatti, non ha il controllo della rete di accesso né di parte della rete di trasporto, tanto che la manutenzione e la risoluzione dei guasti è di pertinenza di Open Fiber.

Lo **schema esemplificativo** che segue spiega ad esempio l'architettura di distribuzione BITSTREAM NGA: come si vede l'operatore è presente solo nella fase di consegna (a monte) e si affida completamente a Open Fiber (o a TIM) sia per la distribuzione ed erogazione del servizio, sia quanto alla rete di trasporto che collega la centrale Open Fiber (o TIM) al Punto di Interconnessione.



L'intera tratta che va dal PDI alle abitazioni dei clienti, indipendentemente dall'architettura posta "a valle" della centrale (FTTC: *Fiber to the Cabinet* / FTTH: *Fiber to the House*), è di pertinenza e gestione del concessionario e trasporta il traffico di tutti gli operatori, separato tramite l'uso delle VLAN

(Virtual LAN).

In definitiva nei contratti di specie:

(i) Fastweb non ha alcun impianto e/o infrastruttura della propria rete nel territorio comunale, come peraltro riconosciuto dall'avviso impugnato;

(ii) Fastweb non può definirsi utilizzatore “materiale” della rete di distribuzione, come richiesto dall'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019: l'accesso all'infrastruttura Open Fiber è infatti **virtuale**, perché l'Operatore non dispone fisicamente e materialmente dell'infrastruttura, né tantomeno la usa in esclusiva. Trattandosi di “**accesso virtuale**”, non è integrata la fattispecie di occupazione mediata perché, come recentemente ribadito, “*l'art. 1, co. 831, nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il Canone Unico sia dovuto dall'utilizzatore non concessionario soltanto là dove si configuri non una utilizzazione purchessia, ma una utilizzazione “materiale” delle infrastrutture... La mera utilizzazione di infrastrutture altrui non veicola di per sé una occupazione di territorio ulteriore, rispetto a quella già oggettivamente determinata dalla presenza delle infrastrutture. L'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro (mero) utilizzatore comporterebbe dunque la duplicazione del pagamento del Canone Unico, in relazione ad un medesimo episodio di occupazione*” (**Trib. Vicenza, sent. 21.01.2025, doc. 8**);

(iii) alla fattispecie illustrata – avente fonte in assetti contrattuali - deve applicarsi la norma di interpretazione autentica, secondo la quale le Società di vendita non sono tenute al pagamento del canone.

Ne deriva che l'impugnato Avviso di Accertamento Esecutivo non può legittimamente fondarsi sull'art. 1, comma 831, della Legge 160/2019.

1.3 Falsa applicazione dell'art. 1, comma 831.

Per quanto sopra chiarito, l'**ipotizzata applicazione del comma 831 è erronea**, in

quanto Fastweb non può essere annoverata fra i “... *soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione...*”.

Infatti, Fastweb, per un verso non è titolare di alcuna concessione di suolo pubblico; per altro verso nemmeno occupa, di fatto, aree di proprietà del Comune in questione.

Mancano, dunque, in radice i presupposti impositivi di cui all'art. 1, comma 823 della Legge n. 160/2019 (“*Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva*”).

Perché possa operare la pretesa economica da parte dell'Ente, dunque, vi deve essere un rapporto concessorio (che manca) ovvero un'occupazione, anche di fatto o mediata dalla interposizione di un'altra infrastruttura, di suolo o spazi pubblici; occupazione che in questo caso è assente.

A definitiva conferma di quanto precede l'**art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021** ha stabilito che il comma 831 deve essere interpretato nel senso che, ove sia riscontrabile una separazione tra il soggetto titolare del contratto di vendita (nel caso di specie, Fastweb) e il soggetto titolare dell'infrastruttura (nel caso di specie, Open Fiber), il primo non realizza né una “occupazione in via mediata” né un “utilizzo materiale” dell'infrastruttura, con la conseguenza che “*il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture*”.

Pertanto, richiedere il canone unico patrimoniale anche ai “soggetti titolari del contratto di vendita” quale è Fastweb nel caso che ci occupa, significa **uplicare l'imposizione** a ingiustificato vantaggio dell'Ente locale, posto che, per un verso, Fastweb è già legata al concessionario da rapporto contrattuale oneroso che già tiene conto degli oneri di occupazione di suolo pubblico e, per altro verso, la

soggettività passiva del concessionario espressamente ricomprende anche le utenze delle società di vendita.

Il sistema delineato dal Legislatore, all'evidenza, non penalizza ma agevola l'Ente concedente (e, parimenti, il concessionario per la riscossione) perché individua un unico interlocutore e soggetto passivo del canone unico patrimoniale, vale a dire il concessionario e, nello stesso tempo, tiene conto che il concessionario già si giova, nei propri rapporti con i meri titolari dei contratti di vendita, di canoni contrattuali più che indennitario per ciascuno degli utenti di Fastweb che viene connesso tramite la sua infrastruttura.

I.4 Applicabilità della norma di interpretazione autentica al settore delle telecomunicazioni.

È appena il caso di precisare, per prevenire infondate obiezioni, che la norma di interpretazione autentica (art. 5, comma 14-*quinquies*, della Legge n. 160/2019) è certamente applicabile anche nel settore delle telecomunicazioni.

Già da un **punto di vista letterale**, l'inequivoco riferimento della norma di interpretazione autentica alle ipotesi di **separazione** (di fonte non solo legislativa e regolamentare, ma **anche contrattuale**) tra titolarità dell'infrastruttura e del contratto di vendita, consente di attrarre pacificamente alla fattispecie considerata anche ciò che si verifica nella fornitura di servizi di telecomunicazione.

La norma, pertanto, si applica in tutti i casi di fornitura in cui il titolare dell'infrastruttura non coincide con il titolare del contratto di vendita.

La **riprova** dell'applicabilità dell'art. 5, comma 14-*quinquies*, al settore delle telecomunicazioni **si rinviene nei lavori parlamentari**.

Il Dossier D.L. 146/2021 – A.C. 3395, infatti, nel presentare la norma, dopo aver premesso che “*il comma 14-quinquies dell'articolo 5, inserito al Senato, contiene una norma di interpretazione autentica della disciplina del canone unico*

patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di **servizi di pubblica utilità**, volte a chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del quantum dovuto, in specifiche ipotesi” chiarisce che **“si tratta di servizi quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete”** (doc. 6, pagg. 59-61; pagg. 61-63 del pdf).

Vi è un altro argomento, parimenti inconfutabile.

In sede di conversione del successivo **D.L. 228/2021** (recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”), sono stati presentati due **emendamenti**, che poi **non** sono stati **approvati**, che miravano proprio a escludere provvisoriamente il settore delle telecomunicazioni dall’applicazione dell’art. 5, comma 14-*quinquies*, sul presupposto logico scontato della omnicomprensività della norma stessa (doc. 7).

- Il primo emendamento non approvato è del seguente tenore:

“Per il settore delle telecomunicazioni, nel caso in cui il soggetto titolare dell'atto di concessione del suolo pubblico non abbia alcun rapporto diretto con l'utente finale ma si limiti, tramite la sua infrastruttura, a permettere ai soggetti titolari del contratto di vendita di distribuire il bene al cliente finale, l'interpretazione di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica fino al 31 dicembre 2022. Per tali soggetti, nell'anno 2022, il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro onnicomprensivi ai sensi dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”

- Il secondo e alternativo emendamento, non approvato, è del seguente tenore:

“In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, fino al 31 dicembre 2022 l'interpretazione autentica si intende riferita esclusivamente ai settori dell'energia elettrica e del gas”. Limitazione dell'interpretazione autentica del canone unico ai settori dell'energia elettrica e del gas fino al 31/12/2022

Tali emendamenti, ripetesi non approvati, sono l'evidente e inconfutabile riprova che l'art. 5, comma 14-*quinquies*, **trova applicazione anche nel settore delle telecomunicazioni**. La proposta di ritardare l'applicazione della norma al settore delle telecomunicazioni non è stata tuttavia approvata perché tali emendamenti non sono stati recepiti nella Legge di conversione del D.L. n. 228/2021, con la conseguenza che sia per il 2022 che per le annualità successive deve essere esclusa la legittimazione passiva delle società di vendita.

* * *

(II)

IN OGNI CASO: DIFETTO DEL REQUISITO DELL'UTILIZZO MATERIALE RICHIESTO DALL'ART. 1, COMMA 831, DELLA LEGGE N. 160/2019. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA.

II.1 In ogni caso, anche a non voler considerare la norma di interpretazione autentica, comunque non ricorrono nel caso di specie presupposti impositivi della “occupazione mediata” e dell'utilizzo materiale delle infrastrutture, espressamente richiesto dal comma 831.

II.2 Col termine “occupazione” si intende la “*sottrazione dell'area all'uso pubblico ed indifferenziato della collettività per destinarla ad un uso singolo e commerciale*” (TAR Lazio – Roma, sez. II-bis, 3 giugno 2021, n. 6533; analogamente Cass. Civ., V, 9 novembre 2021, n. 32869, secondo cui si ha occupazione, ai fini dell'applicazione delle norme TOSAP, quando si determini “*un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico*”).

L'occupazione, pertanto, presuppone una “**relazione materiale instaurata con la cosa**” da parte dell'occupante (cfr. Cass. Civ., sez. V, sent. 8 settembre 2017, n. 21018). Sul punto, Cass. Civ., ss. uu., 7 maggio 2020, n. 8628, ha ulteriormente precisato che la “*relazione materiale instaurata con la cosa*” è condizione

necessaria e sufficiente perché possa parlarsi di occupazione di suolo pubblico, indipendentemente dall'esistenza e dalle caratteristiche di un titolo giuridico che giustifica l'occupazione stessa. Il punto è ribadito anche da Cass. Civ., sez. V, 16 novembre 2021, n. 34591.

Anche l'occupazione mediata richiede dunque una *“relazione materiale instaurata con la cosa”* che dovrà essere diversa dalla occupazione diretta, dovrà essere “mediata” dalla infrastruttura del concessionario, ma non potrà essere del tutto assente. Questo requisito è stato individuato, nel testo vigente, appunto con l'indicazione per cui l'occupazione in via mediata avviene *“attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”*.

L'espressione “utilizzo” non può essere letta estensivamente; per un'elementare esigenza di coerenza sistematica, deve essere intesa in conformità con la nozione generale di “occupazione” (specificata al comma 819 ma rinvenibile nella complessiva disciplina di cui ai commi da 816 a 836, oltre che nella giurisprudenza sopra citata) e quindi deve ritenersi che richieda almeno la presenza stabile, sull'infrastruttura del concessionario, di oggetti materiali di cui l'occupante mediato abbia la disponibilità. Altrimenti, non si ha utilizzo materiale, bensì virtuale.

Per esplicitare un esempio concreto di *“occupazione mediata realizzata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”*, basti pensare all'utilizzo di un cavidotto di protezione (per rete idrica o rete elettrica o rete per telecomunicazioni o altro ancora) realizzato dal titolare della concessione del suolo pubblico (meglio sottosuolo) e che venga utilizzato anche per farvi passare e proteggere altro cavo elettrico o il cavo in fibra ottica di un altro soggetto. In questo caso si avrebbe un titolare della concessione che occupa il suolo pubblico e si avrebbe altresì una “occupazione mediata” dello stesso suolo attraverso l'**utilizzo materiale** del cavidotto.

Questa relazione materiale (mediata) fra gli impianti-cavi di un soggetto ed il territorio comunale si realizza frequentemente, ad esempio quando gli Enti provvedono a far concentrare e utilizzare congiuntamente talune infrastrutture come previsto, fra gli altri, dal D.Lgs. n. 33/2016.

La necessità di una relazione materiale trova conferma nella disciplina sanzionatoria delle occupazioni abusive laddove è prescritto (art. 1, comma 822) che *“gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni ... priv(e) della prescritta concessione o autorizzazione o effettuat(e) in difformità dalle stesse o per (le quali) non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone”*, con ciò dando per scontato che alla abusività corrisponde una materialità da rimuovere.

In definitiva, nel caso di specie, Fastweb non ha alcun materiale rapporto con le condutture, perché non ha la materiale disponibilità delle stesse, non può usarle in modo esclusivo e non cura nemmeno la relativa manutenzione. È quindi semplice fruitore del servizio di rete fornito dal titolare della concessione sulla base di assetti contrattuali rispettosi dei principi elaborati dall'Autorità di settore e disponibili per tutti gli Operatori licenziatari.

II.3 Ora, è agevole verificare che il Comune di Berbenno, preso atto che Fastweb non ha la titolarità della rete, pretende il versamento del canone anche da parte di Fastweb *“... per l'utilizzo in via mediata della rete di proprietà del soggetto titolare della concessione”* ma, a ben vedere, confessa di non aver tenuto conto del necessario requisito dell' *“utilizzo materiale dell'infrastruttura”*; tanto è vero che nell'avviso di accertamento, nella *“motivazione dell'atto”* precisa *“...senza che sia quindi necessaria alcuna occupazione fisica o modificazione della realtà”*. Risulta con ciò evidente che il Comune, disapplicando il comma 831, pretende il canone in difetto di un presupposto essenziale (utilizzo materiale) e, nel contempo, pretende di duplicare il canone per un'occupazione fisica che è in realtà unica.

II.4 Ne consegue che, anche a voler prescindere dall'applicabilità della norma di interpretazione autentica (art. 5, comma 14-quinquies, D.L. n. 146/2021), non sussistono i presupposti impositivi di cui all'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, né quelli degli artt. 48, comma 8, e 51 del “*Regolamento comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico e di Esposizione Pubblicitaria*” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Berbenno n. 8 del 6.04.2021 (**doc. 6**), atteso che, per quanto chiarito, Fastweb non realizza un'occupazione permanente di suolo pubblico ulteriore rispetto a quella del titolare della concessione.

* * * * *

(I-II)

SUI NUMEROSI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI RESI SUL TEMA.

È importante ora dar conto che **altri avvisi di accertamento analoghi** a quello adottato dal Comune di Berbenno sono stati **annullati in sede giurisdizionale** in accoglimento di opposizioni analoghe e con motivazioni basate su **duplice ratio decidendi** ossia, da un lato, sulla valorizzazione della norma di interpretazione autentica, dall'altro lato, sulla accertata non ricorrenza nel caso di specie del requisito dell' “*utilizzo materiale dell'infrastruttura*”, espressamente richiesto dal comma 831. In particolare, con la **sentenza 21 gennaio 2025, n. 83** (**doc. 8**), il **Tribunale di Vicenza**, in un caso perfettamente analogo, ha accolto l'opposizione precisando, quanto alla norma di interpretazione autentica, che:

“... si tratta di disposizione che si attaglia pienamente al caso di specie nel quale vi sono, da un lato, un soggetto (TIM) proprietario di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il Comune di Thiene e, dall'altro lato, un soggetto (Vodafone) che, sulla scorta di rapporti contrattuali intrattenuti con TIM, è mero titolare dei contratti di vendita di un bene che viene distribuito esclusivamente dalle infrastrutture di TIM. A norma dell'art. 5, co. 14 quinquies del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, Vodafone, quanto all'anno 2021 qui in esame, non è dunque tenuta al pagamento al Comune di Thiene del Canone Unico di cui all'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019”;

interpretazione autentica trova corrispondenza nel dato di fatto, non contestato in giudizio”, con la conseguenza che “i concetti di “uso materiale” delle infrastrutture e di “occupazione in via mediata” delle stesse sono da escludersi. Infatti non solo Vodafone (in astratto e secondo le categorie del mercato di riferimento) non occupa e non usa la rete di TIM perché ciò è chiarito dalla norma di legge; ma anche in concreto, come detto secondo la ricostruzione offerta e non contestata, l’attrice non ha relazione materiale con gli impianti presenti sul territorio di Selvazzano Dentro”.

= in altro caso identico **Trib. Padova, Sez. II, sent. 2 gennaio 2024** (che si produce: **doc. 10**) che, con articolata motivazione, ha osservato, tra l’altro, che:

*“la norma di interpretazione autentica ... nello stabilire che “il **canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture**” precisa che tale canone viene versato “in base alle utenze delle predette società di vendita”. Il concessionario, pertanto, è onerato non solo per le proprie utenze, ma anche per quelle delle altre eventuali società di vendita. Pertanto, richiedere il canone anche ai “soggetti titolari del contratto di vendita” quale è Vodafone nella specie, **significherebbe duplicare l’imposizione** a ingiustificato vantaggio dell’Ente locale (ovvero significherebbe rivolgersi a soggetto privo di legittimazione passiva). Infatti, per un verso, Vodafone è già legata al concessionario da rapporto contrattuale (oneroso) e, per altro verso, **la soggettività passiva del concessionario espressamente ricomprende anche le utenze delle società di vendita**. Il criterio delle utenze si applica, dunque, esclusivamente nei rapporti tra concessionario e concedente e nessuna norma prescrive che l’utilizzatore non materiale dell’infrastruttura (Vodafone) debba rendere una dichiarazione circa il numero delle utenze al Comune, e tantomeno al concessionario, essendo il relativo rapporto contrattuale basato su parametri diversi. Del resto, TIM, quale titolare e unica utilizzatrice dell’infrastruttura, e quale Società che cura materialmente gli allacci e i collegamenti su richiesta delle società di vendita, è ben a conoscenza del numero e della dislocazione dei collegamenti e, dunque, del numero delle utenze di ciascuna società di vendita ed è perfettamente in grado di farne dichiarazione. **Il Comune, peraltro, non riceve da tale assetto alcun pregiudizio**, perché il canone di occupazione di suolo pubblico che il concessionario deve versare deve essere calcolato in base al numero complessivo delle utenze, sia quelle che fanno capo alla società concessionaria che quelle che fanno capo alle società di vendita; sicché **ciascun Comune è anche avvantaggiato nella riscossione del canone perché deve di regola interfacciarsi con unico interlocutore (nel caso di specie, TIM) che è tenuto alla dichiarazione complessiva delle utenze**.*

Quindi il Legislatore, attraverso il comma 831 come autenticamente interpretato, agevola l’Ente concedente perché individua un unico interlocutore e soggetto passivo del canone unico patrimoniale, vale a dire il concessionario e, nello stesso

tempo, tiene conto che **il concessionario già si giova, nei propri rapporti con i meri titolari dei contratti di vendita, di canoni contrattuali**, la congruità e modalità della cui quantificazione non è oggetto di questo giudizio. Certo è che è palesemente erroneo far discendere la soggettività passiva di Vodafone dalla mera titolarità di utenze (contratti di vendita) nel Comune, essendo tale presunto accertamento insufficiente e inidoneo a fondare la legittimazione passiva di Vodafone che, in questo caso, è positivamente esclusa dalla Legge".E ha aggiunto che una diversa interpretazione "...realizzerebbe un **contrasto col diritto comunitario** (art. 13 Direttiva 2002/20/CE e art. 42 Direttiva UE 2018/1972), posto che i contributi devono essere giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito e giammai "duplicati" ...".

= ancora, **Trib. Perugia, sent. 5 luglio 2024 (doc. 11)** secondo la quale:

*"non risultano dubbi in merito al fondamento dell'opposizione avanzata da Vodafone Italia Spa che, nel caso concreto, come dalla stessa giustamente sostenuto, **difetta della presenza di infrastrutture materiali nel territorio del Comune** di Corciano e/o di concessioni da parte dello stesso Comune per l'istallazione di infrastrutture nel territorio del medesimo, mentre **intrattiene rapporti contrattuali con TIM** per la fornitura di servizi di telecomunicazione che, tuttavia, si svolge **senza il materiale rapporto con le condutture, che non sono occupate da materiali/cavi della Vodafone**, la quale, peraltro, non usa il collegamento in maniera esclusiva né si occupa della manutenzione, sostanziosamente - Vodafone Italia Spa - come nient'altro che una società di vendita".*

= ancora, **Trib. La Spezia, sent. 21 marzo 2025 (doc. 12)**, secondo cui:

*"il servizio viene erogato mediante l'**accesso solo virtuale alla rete TIM** tramite tecnologia VULA, senza alcuna occupazione materiale del suolo pubblico... Questo tipo di utilizzo **non configura una occupazione mediata del suolo pubblico** e utilizzo materiale dell'infrastruttura, poiché la rete TIM è già soggetta a concessione, Vodafone non la utilizza per posare propri cavi all'interno della medesima e il canone è dunque interamente versato dalla proprietaria-occupante. E cioè la mera utilizzazione di infrastrutture altrui non importa di per sé un'occupazione ulteriore rispetto a quella determinata dalla presenza delle infrastrutture, salvo il caso in cui, come già anticipato, l'operatore telefonico non si sia limitato ad una utilizzazione virtuale, ma abbia a sua volta posato dei propri cavi all'interno dell'infrastruttura Telecom.*

= ancora, **Trib. Perugia, sent. 18 marzo 2025 (doc. 13)** secondo la quale:

*“La norma ha introdotto l’occupazione mediata del territorio che richiede una relazione materiale con la cosa che deve essere mediata dalla infrastruttura del concessionario. La norma sopra indicata fa riferimento quindi all’utilizzo di infrastrutture materiali del concessionario di cui l’occupante mediato abbia la disponibilità. Nel caso di specie Vodafone non occupa e non usa la rete Tim e comunque **non ha alcuna relazione materiale con gli impianti** presenti nel territorio di Umbertide”.*

= e **Trib. Asti, sent. 12 marzo 2025 (doc. 14)**, secondo la quale:

*“la dizione normativa postula ... un rapporto di utilizzazione materiale delle infrastrutture, da parte di soggetto diverso dal concessionario (nel caso di specie, TIM), il che implica però, se si vuol dare un senso al nomen iuris adottato dal legislatore, la fruizione, effettiva, da parte di soggetto altro, rispetto al concessionario, dei manufatti da quest’ultimo collocati e posti in opera. **Nel caso in esame, sussiste un rapporto meramente virtuale** tra la impiantistica TIM, sita in Castello D’Annone, e punti di raccolta Vodafone, situati altrove, il che esclude la applicabilità della norma”*

= nonché **Trib. Rovigo, sent. 10 marzo 2025 (doc. 15)**, che ha osservato:

“l’imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro utilizzatore, comporterebbe la duplicazione del pagamento del Canone Unico, in relazione ad un medesimo ed unico episodio di occupazione. ... il caso in esame è pienamente riconducibile al perimetro applicativo della norma sopra riportata, atteso che TIM è proprietaria di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il Comune di Adria, mentre Vodafone, sulla scorta di rapporti contrattuali intrattenuti con TIM, è mero titolare dei contratti di vendita di un bene che viene distribuito esclusivamente dalle infrastrutture di TIM”.

Di qui la fondatezza dell’opposizione.

* * *

(III)

IN VIA SUBORDINATA: MANCANZA DI FORMALE CONTESTAZIONE.

VIOLAZIONE DELL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO COMUNALE.

I motivi che precedono sono dirimenti e assorbenti, posto che il relativo

accoglimento comporta l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. In via subordinata, per la non creduta ipotesi di rigetto dei precedenti motivi di opposizione, si rappresenta quanto segue.

Si è già detto, ed è espressamente riconosciuto nel provvedimento impugnato, che Fastweb S.p.A. non è titolare di alcuna concessione di suolo pubblico nel territorio di Berbenno, né è tenuta a richiedere tale concessione.

Ora, l'art. 51 del Regolamento Comunale (**doc. 3**) che disciplina il canone patrimoniale di occupazione, stabilisce che *“il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto”*.

Nessuna delle due evenienze si verifica nel caso di specie. Infatti, ammesso e non concesso che possa parlarsi di “occupazione”, l'occupante di fatto (abusivo) è soggetto passivo solo in mancanza di un titolare della concessione, che invece in questo caso esiste certamente.

Ad ogni modo, a mente dell'**art. 36**, comma 1, del citato Regolamento, le *“occupazioni realizzate senza la concessione ... sono considerate abusive”* e, come stabilito dal comma successivo *“in tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative”*.

Ne deriva, da un lato, la conferma che in tutti i casi di occupazione vi deve essere una materialità, ossia una modificazione della realtà, riguardante un'area che non sia già attribuita in concessione.

Ne deriva, inoltre e per quanto qui rileva, che la pretesa recuperatoria nei confronti di soggetto che non sia titolare di concessione deve essere sempre

preceduta da un verbale di accertamento (ad opera della Polizia locale o dell'agente accertatore), circostanza che nel caso di specie non si è verificata.

Di qui un ulteriore vizio del provvedimento impugnato.

* * *

(IV)

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: ILLEGITTIMA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE DA OMESSO VERSAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 58 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL CANONE PATRIMONIALE.

In via ulteriormente subordinata, va contestata la quantificazione della sanzione comminata.

Come detto, il Comune di Berbenno ha ritenuto di applicare, per l'omesso versamento del canone, una “*sanzione amministrativa pecuniaria*” definita “*nella misura del 100% dell'importo dovuto*”.

Pertanto, la sanzione applicata (€ 3.484,43) è pari alla somma dei canoni pretesi per ciascuna delle quattro annualità richieste (€ 800,00 + € 830,40 + € 924,24 + € 929,79= € 3.484,43).

La misura della sanzione è tuttavia illegittima, considerato che il Regolamento Comunale di Berbenno (**doc. 3**) che disciplina il canone patrimoniale di occupazione, all'**art. 58**, rubricato “*Sanzioni*” stabilisce inequivocabilmente che “... **sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre gli interessi legali**”.

Ne deriva che la sanzione è stata erroneamente quantificata in misura pari al canone asseritamente omesso (€ 3.484,43) anziché nella misura del 30% del canone asseritamente omesso, ossia € 1.045,32.

Pertanto, il Comune, pur avendo espressamente disciplinato la misura della

sanzione, in virtù del proprio potere regolamentare conferito dalla Legge e che può spingersi fino alla istituzione di esenzioni e riduzioni, ha apertamente violato l'art. 58 del proprio Regolamento, senza giustificazione alcuna.

Di qui, un ulteriore motivo di annullamento dell'avviso impugnato.

* * * * *

Per tutte le ragioni sopra esposte, e, comunque per quelle di giustizia, e con ogni più ampia riserva di ulteriormente eccepire, dedurre, produrre e di formulare conclusioni integrative e istanze, anche istruttorie, nei termini di rito, Fastweb S.p.A., come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

CITA

il **COMUNE DI BERBENNO** (C.F. 00313890162), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Via Europa n. 7 – 016023 Berbenno (BG), PEC comuneberbenno@legalmail.it (estratta da Registro IPA), a comparire avanti al Tribunale di Bergamo, Sezione e Giudice designandi all'udienza che sarà tenuta il **29 settembre 2025**, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite all'art. 166 c.p.c. e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. Avverte inoltre che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che la mancata comparizione alla suindicata udienza comporterà la prosecuzione del processo in sua dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni,

accertato che Fastweb S.p.A. non è concessionaria dell'infrastruttura di rete sita su territorio comunale e che non ha l'utilizzo materiale della stessa, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, in tutto in parte, l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 1 del 6.02.2025 emesso dal Comune di Berbenno, e ogni altro atto o avviso ad esso connesso o consequenziale, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto e in diritto. Conseguentemente accertare che nulla è dovuto da Fastweb S.p.A. al Comune di Berbenno per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024 a titolo di canone unico patrimoniale, indennità, interessi e, comunque, a titolo di sanzioni; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.

In via istruttoria, si producono, oltre all'originale notificato del presente atto di citazione, i seguenti documenti in copia: **1) Avviso di accertamento esecutivo n. 1 del 6.02.2025**; **2) Notifica pec avviso di accertamento in data 15.02.2025**; **3) Regolamento Comunale CUP Berbenno**; **4) Elenco Operatori estratto da sito Open Fiber**; **5) Delibera 538/13/CONS di Agcom**; **6) Dossier Senato conversione DL 146/2021**; **7) Emendamenti al D.L. 228/2021 non approvati**; **8) Trib. Vicenza, sent. 21.1.2025**; **9) Trib. Padova sent. 20.9.2023**; **10) Trib. Padova sent. 2.1.2024**; **11) Trib. Perugia, sent. 5.7.2024**; **12) Trib. La Spezia, sent. 21 marzo 2025**; **13) Trib. Perugia, sent. 18 marzo 2025**; **14) Trib. Asti, sent. 12 marzo 2025**; **15) Trib. Rovigo, sent. 10 marzo 2025**.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa ammonta ad € 7.173,00 e che pertanto il contributo unificato è dovuto e sarà anticipato nella misura di € 237,00, oltre diritti di cancelleria.

Roma, 16 aprile 2025

Avv. Paolo Caruso